

1500721-65.2022.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Prisão em flagrante

Magistrado: Juliana Maria Maccari Gonçalves

Comarca: Embu das Artes

Foro: Foro de Embu das Artes

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 18/08/2022

... conjunta de diversas viaturas para apuração do tráfico de entorpecentes ocorrido no local. Ao se dirigirem até lá, encontraram a acusada caminhando em uma viela, com uma bolsa a tiracolo e, indagada, a acusada confessou informalmente que estava na prática do tráfico de drogas.

Os depoimentos se encontram em consonância com os elementos de informação colhidos na fase ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu das Artes

Foro de Embu das Artes

1ª Vara Judicial

Avenida Vereador Jorge de Souza, nº 855, Embu das Artes-SP - cep 06803-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500721-65.2022.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500721-65.2022.8.26.0628

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Prisão em flagrante

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2104154/2022 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 24336607 -

DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 2104154 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCILENE CRISTINA PEREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MARIA MACCARI PAUFERRO

Vistos.

I - RELATÓRIO

LUCILENE CRISTINA PEREIRA, qualificada nos autos, foi denunciada pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", cumulado com o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, pois, no dia 14 de abril de 2022, por volta das 23h, na Rua da Liberdade, nº 100, nesta Comarca, trazia consigo, vendia e guardava, para fins de tráfico, 104 (cento e quatro) porções de cocaína, 48 (quarenta e oito) porções de "maconha" e 13 (treze) porções de "crack", tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 50/52).

Consta da inicial acusatória que, na data dos fatos, guardas civis municipais

receberam a informação de que uma mulher estava praticando o tráfico de drogas e se dirigiram até o local. Lá chegando, a denunciada foi revistada e, em seu poder, foram encontrados os entorpecentes descritos, todos embalados individualmente e prontos para a comercialização, tudo nas imediações da Escola Municipal Reynaldo Ramos de S. Da Gama.

A denúncia foi recebida em 29 de abril de 2022 (fls. 75/76).

A ré constituiu advogado e apresentou resposta à acusação (fls. 87/89).

Ratificado o recebimento da denúncia, foram ouvidas cinco testemunhas. Ao final, a ré foi interrogada.

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público requereu a parcial procedência da ação penal, com a exasperação da pena-base em razão da natureza e quantidade das drogas apreendidas, o afastamento da causa de aumento indicada na inicial acusatória, bem como do privilégio previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, além da imposição de regime inicial fechado.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição, ante a ausência de prova quanto à participação da ré no delito ou a insuficiência probatória. Em caso de condenação, pleiteou o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, o reconhecimento do benefício previsto no art. 33, §4º, da mesma lei, em seu patamar máximo, e a concessão da prisão domiciliar, pela existência de filho menor (fls. 138/149).

É o relatório. Fundamento e decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

A ação penal é parcialmente procedente.

Trata-se, na hipótese, de acusação pelo cometimento das seguintes infrações penais: "Lei nº 11.343/06, Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos." Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1), Boletim de Ocorrência (fls. 9/10), auto de exibição/apreensão (fls. 12), laudo de constatação (fls. 14/17), bem como laudo de exame químico-toxicológico com resultado positivo para "cocaína" e "maconha" (fls. 132/134).

A autoria também é certa.

Silente em sede policial (fls. 04), a ré LUCILENE CRISTINA PEREIRA negou a imputação. Disse que, na data dos fatos, tinha combinado com três amigas suas de ir para um bar naquela região. Em determinado momento avistou duas viaturas, e uma delas parou e realizaram a abordagem. Perguntaram onde morava e quem tinha passagem. A ré disse então que tinha passagem e foi levada para uma viela. Lá, mostrou o que tinha nos bolsos e nada foi encontrado. Disseram que seria encaminhada até uma Delegacia para averiguação. Não chegou a ver os entorpecentes, apenas que os guardas encontraram uma bolsa e vieram dizendo "olha o que achamos", mas a bolsa não era sua.

No entanto, a versão exculpatória apresentada pela acusada - de que apenas estaria no local para confraternizar com suas amigas, desconhecendo os entorpecentes localizados pelos guardas - não merece acolhida, já que colide com os demais elementos de prova existentes nos autos.

Ouvido em Juízo, o guarda civil municipal IZAC DE SOUZA PINTO relatou que a ré foi

encontrada no local com diversas porções de cocaína, "maconha" e "crack". Narrou que recebeu informações sobre a traficância praticada pela ré no local dos fatos. As notícias indicavam que havia um indivíduo de blusa azul traficando, mas no local foi encontrada a ré na posse dos entorpecentes. A droga estava dentro de uma bolsa, em poder da ré, que estava caminhando quando foi abordada. No momento, admitiu informalmente o tráfico de entorpecentes. Afirmou não conhecer a acusada de outras abordagens. Ao final, acrescentou que, em local próximo à abordagem, não havia uma escola.

No mesmo sentido, as declarações do guarda civil municipal FERNANDO RINALDI, que também participou da diligência. Narrou que houve uma informação repassada, o que gerou uma operação conjunta de diversas viaturas para apuração do tráfico de entorpecentes ocorrido no local. Ao se dirigirem até lá, encontraram a acusada caminhando em uma viela, com uma bolsa a tiracolo e, indagada, a acusada confessou informalmente que estava na prática do tráfico de drogas.

Os depoimentos se encontram em consonância com os elementos de informação colhidos na fase policial, que indicam que a abordagem da acusada foi realizada no contexto de atividade de mercancia de entorpecentes.

No mais, é certo que o simples fato de as testemunhas ouvidas serem guardas civis municipais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que sejam recebidos com reservas, mesmo que não tenham sido arroladas outras testemunhas presenciais dos fatos pelo órgão acusatório.

Nesse contexto, é de rigor salientar o entendimento pacífico da jurisprudência no sentido de que os depoimentos de policiais não podem ser desconsiderados ou desacreditados apenas por sua condição, tendo em vista a ausência de proibição de que, como qualquer cidadão, prestem testemunho sob o compromisso da lei.

Assim, a desconsideração do depoimento policial apenas se dá quando configurados atos de parcialidade, motivados por vingança, perseguição ou interesse na causa, os quais deverão ser demonstrados de forma segura e objetiva no caso concreto, o que não ocorreu na hipótese em apreço.

Ressalto que a diligência promovida neste processo decorreu de patrulhamento de rotina, destinada à apuração de notícia da ocorrência de venda de droga no local, não estando presente, no caso concreto, qualquer indício de que referida abordagem tenha se dirigido de maneira específica a incriminar a acusada, gerando dúvidas em relação à eventual suspeição dos referidos agentes.

Sobre o tema, já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Apelações - Tráfico de drogas - Recursos da defesa e da acusação. Apelos defensivos - Pedido de absolvição por falta de provas - Não acolhimento - Materialidade e autoria comprovadas - Corréus que apresentaram versões contraditórias, rechaçadas pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, uníssonos durante toda a persecução penal - Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, mormente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade (...)" (Apelação nº 0000179-03.2017.8.26.0530, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Juscelino Batista, j. 20.05.2021).

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Condenação - Recurso defensivo - Absolvição por insuficiência probatória da autoria - Inocorrência - Depoimentos coerentes dos policiais militares - Confissão na Delegacia de Polícia - Elevadíssima quantidade de entorpecente - Ausência de indícios de imparcialidade dos policiais - Recurso não provido." (Apelação nº 0017236-44.2014.8.26.0302, 7ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Alberto Anderson Filho, j. 28.07.2016).

Reputo, portanto, idônea a prova oral produzida pela acusação.

A testemunha de defesa EUNICE APARECIDA DA SILVA ROCHA, ouvida como informante na audiência, narrou que conhece a vítima há alguns anos e trabalha em uma padaria de propriedade da acusada. Essa padaria fica próxima à casa da ré, onde também reside a depoente. A acusada possui dois filhos, um de 5 anos e uma de 16 anos. Sabe que é solteira e cria as crianças sozinha. Na data dos fatos, combinou com a ré que fariam um almoço juntas, a depoente foi comprar um peixe e, quando estava voltando, avistou a acusada com uma outra menina em um bar. Viu duas viaturas subindo, e abordaram a ré, em frente a um bar e, depois, perto de uma viela. Não presenciou a revista corporal.

A testemunha VANESSA CRISTINA VERÍSSIMO DA SILVA declarou que também trabalha na padaria com a acusada. Na data dos fatos, das 15h às 22h, mais ou menos, estava na padaria com a ré. Foram subindo a rua e pararam num bar próximo para beber cerveja. Não demorou muito, chegaram duas viaturas. No bar, havia mais duas meninas, que começaram a rir. Os guardas então fizeram a abordagem e perguntaram se alguém ali tinha passagem. A ré respondeu que ela tinha passagem, e os guardas então a conduziram "para o fundo".

Questionadas, ambas as depoentes, que afirmaram ser amigas da ré e trabalharem juntas com a acusada, disseram desconhecer qualquer envolvimento da ré com o tráfico de entorpecentes, mesmo a acusada tendo sido condenada em agosto de 2021 também pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei de Drogas, a pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime fechado.

A natureza da relação entre tais depoentes e a acusada, aliada à circunstância de que não presenciaram, de fato, o efetivo momento em que os guardas civis municipais localizaram as drogas em questão juntamente à ré, impede que tais depoimentos infirmem a versão apresentada pelos agentes policiais.

No mais, a quantidade de droga apreendida, sua variedade e forma de acondicionamento, se revelam suficientes para caracterizar o crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

E, considerando que não há qualquer outro elemento nos autos capaz de por em dúvida esta conclusão, de rigor o acolhimento da pretensão punitiva, com a consequente condenação da acusada nos moldes indicados na inicial acusatória.

Passo, então, a individualizar a pena.

Em atenção aos ditames do art. 59 do Código Penal, observo que a ré possui outra anotação relativa à prática de tráfico de entorpecentes (autos nº 1501101-59.2020.8.26.0628 - fls. 106/107), cuja sentença ainda não transitou em julgado, razão pela qual inviável sua valoração como mau antecedente.

Além disso, não há nos autos qualquer informação que prejudique a ré no que tange à culpabilidade, à conduta social, à sua personalidade, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime, que são todas normais à espécie.

Verifico, ainda, que de acordo com o laudo de constatação de fls. 14/17, foram localizadas com a ré 2,6g líquidas de "cocaína", no item 1, 51,2g de "cocaína", no item 2, e 98,4g de "maconha", no item 3.

Entendo, todavia, ser incabível o aumento da pena nesta fase com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/06, em razão da quantidade e da natureza dos entorpecentes trazidos com a acusada, sob pena de restar configurado o "bis in idem", já que tais circunstâncias serão valoradas na terceira fase da dosimetria penal.

É o caso, portanto, de se aplicar a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, de rigor o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a ausência de demonstração da existência de estabelecimento de ensino em local próximo ao lugar em que a ré foi abordada, o que foi, inclusive, reconhecido pelo órgão ministerial em suas alegações finais.

Por outro lado, entendo cabível a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, do mesmo diploma legal.

Isto porque, conforme já dito, apesar de a acusada responder a outra acusação da prática de tráfico de entorpecentes, a sentença condenatória proferida nos autos registrados sob o nº 1501101-59.2020.8.26.0628 ainda não transitou em julgado. E tal circunstância, por si só, impede a conclusão no sentido de que a ré se dedica de forma inequívoca a atividades criminosas.

Tal entendimento foi, inclusive, recentemente pacificado em tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Recurso Especial nº 1.977.180/PR, relativo ao Tema nº 1.139, segundo a qual "é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06".

Este foi, também, o entendimento exposto no seguinte julgado, proferido pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, cuja ementa segue transcrita:

"APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas privilegiado. Sentença condenatória. Irresignado, Ministério Público requer a majoração da pena-base; a compensação integral entre a atenuante da menoridade relativa e da agravante de calamidade pública; o afastamento do redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas e, por fim, a fixação de regime inicial fechado. Sem razão. Materialidade e autoria indúvidas. Réu guardava e tinha em depósito 25 (vinte e cinco) porções de cocaína, com peso de 5 g (cinco gramas), 21 (vinte e uma) porções de crack, com peso de 5 g (cinco gramas) e 13 (treze) porções de maconha, com peso de 14g (catorze gramas). Finalidade de mercancia caracterizada pelas circunstâncias do flagrante. Conjunto probatório robusto para o delito imputado ao réu na denúncia. Condenação de rigor, sequer objeto de recurso. Dosimetria comporta reparo. Pena-base mantida no mínimo legal. Compensação da atenuante da menoridade relativa com a agravante da calamidade pública, sem reflexo na pena. Na terceira etapa, não se há falar em valoração de ação penal em curso para afastar a figura privilegiada do tráfico de drogas. Precedente. Regime aberto e substituição por restritivas de direitos de rigor. Recurso improvido." (Apelação nº 1500624-93.2021.8.26.0533; 1ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Andrade Sampaio, j. 27.06.2022).

Nesse ponto, vale ainda destacar que é ônus da acusação demonstrar o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, em observância ao princípio da presunção de inocência, devendo haver prova certa da concreta dedicação à atividade criminosa ou da integração a organização criminosa, a fim de se afastar o benefício, não sendo este o caso dos autos. Entendo cabível, todavia, a aplicação do redutor em seu patamar mínimo, ou seja, 1/6 (um sexto), já que a ré foi encontrada com quantidade considerável de entorpecentes, de naturezas diversas, consistentes em maconha e cocaína, esta última com alto poder deletério, justificando, com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/06, a diminuição do patamar redutor.

Assim, a pena final aplicada à ré é de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Diante da ausência de informações a respeito das condições socioeconômicas da acusada, fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal.

Tendo em vista a natureza e quantidade das drogas apreendidas, que serviram inclusive à fixação do patamar mínimo de redução do privilégio, e a quantidade da reprimenda, e considerando o teor das Súmulas nº 440, 718 e 719, a primeira do C. Superior Tribunal de Justiça e as demais do C. Supremo Tribunal Federal, fixo o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, nos moldes do art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal, o qual reputo suficiente para atingir as finalidades da pena, consistentes na prevenção geral e especial e na retribuição, estando tal entendimento respaldado por julgado proferido pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo (Apelação nº 1523060-25.2020.8.26.0228, 16ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Camargo Aranha Filho, j. 07.06.2021).

Incabível, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, já que ausentes os requisitos expressamente previstos nos arts. 44, inciso I, e 77, "caput", do Código Penal.

III - DISPOSTIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal, a fim de condenar a ré LUCILENE CRISTINA PEREIRA, por incursão no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, calculados na base do valor unitário mínimo.

Indefiro à acusada o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que teve sua prisão preventiva decretada durante o curso processual (fls. 31/34), e permanecem presentes os requisitos autorizadores desta providência cautelar, especialmente a necessidade de se garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Deixo, todavia, de aplicar o disposto no §2º do art. 387 do Código de Processo Penal, uma vez que eventual detração operada nestes autos não teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena ora fixado, não obstante o período de prisão preventiva da sentenciada, além de entender, de todo modo, que o Juízo da Execução Penal possui melhores condições de apreciar todos os requisitos

necessários à eventual progressão para regime diverso do ora fixado. Contudo, considerando a fixação do regime inicial semiaberto, determino a expedição de guia provisória de execução penal, em atenção ao que determina a Súmula 716 do C. Supremo Tribunal Federal, a fim de que sejam implementadas as condições do regime ora imposto (STF, HC 180957, Segunda Turma, DJe 13.05.2020, RHC 166279/SP, Segunda Turma, DJe 2.2.2020; HC 123267, Primeira Turma, DJe 02.02.2015; STF, HC 118528, Primeira Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 14.02.2014), tal como admitido também pelo C. Superior Tribunal de Justiça (RHC 12.561/GO, Quinta Turma, DJe 29.06.2020, RHC 75.051/MG, Sexta Turma, DJe 16.12.2016), salvo se da unificação de penas resultar a imposição de regime mais gravoso pelo Juízo da Execução Penal (Lei de Execução Penal, art. 111, parágrafo único). Indefiro, por fim, o pedido de concessão de prisão domiciliar, uma vez inexistir nos autos prova idônea de que a sentenciada seja genitora do menor indicado nas alegações finais apresentadas pela Defesa, não se cumprindo o requisito previsto no art. 218, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Condeno a ré ao pagamento de custas, com fulcro no art. 804 da referida lei, mas lhe concedo os benefícios da justiça gratuita, devendo a Serventia proceder às anotações cabíveis. Autorizo a destruição de eventual contraprova, nos termos do art. 72 da Lei de Drogas. Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE, considerando o disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal, e ao Instituto de Identificação (IIRGD). Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Embu das Artes, 04 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA